

1501544-27.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirma que um dos acusados - de branco em audiência - lançou objeto na rua. Encontraram entorpecentes com ambos. Um deles - acusado vestido de branco - afirmou que estava no local para vender entorpecentes. Esse foi questionado por qual razão estaria praticando tráfico de drogas, uma vez que é conhecido como usuário de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501544-27.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501544-27.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164785/2022 - DEL.POL.ARUJA, 25615457 - DEL.POL.ARUJA, 2164785 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN CRISTIANO ALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de MAYCON VIANA PONTES e KELVIN CRISTIANO ALVES, já qualificados, imputando-lhes a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, nas circunstâncias de local e tempo descritas na denúncia (no dia 18 de junho de 2022, à tarde, na Rua Sete de Setembro, 686, Jd. Monte Serrat, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel), agindo em concurso e unidade de desígnios, traziam consigo, para fornecimento a terceiros, 26 (vinte e seis) invólucros plásticos, contendo 6,90g (seis gramas e noventa decigramas) de cocaína em forma de

crack, e 01 (uma) porção, contendo 0,70g (setenta decigramas) de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização legal.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi determinado o processamento da ação penal (fls. 105/106). Apresentada resposta à acusação (fls. 132/134 e fls. 138/140). A denúncia, então, foi formalmente recebida (fls. 152).

No curso da instrução, realizada nesta data, colheu-se depoimento das testemunhas policiais e ao final foram os réus interrogados.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa dos réus, em memoriais, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pugnaram pela desclassificação do crime e formularam requerimentos destinados a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.
Fundamento e decido.

I – Das provas produzidas e sua valoração

I.1 Crime de tráfico tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é parcialmente procedente. As provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria do réu KELVIN CRISTIANO ALVES pelo fato a ele imputado.

O auto de exibição e apreensão que instruiu o auto de prisão em flagrante dá conta da apreensão da substância entorpecente descrita na denúncia (fls. 22). As substâncias foram submetidas a exame preliminar de constatação, cujo laudo também foi juntado aos autos (fls. 19/21), de modo que constatada sua natureza. A apuração preliminar foi confirmada com o a realização do exame químico toxicológico (fls. 190/191).

A posse da droga pelo réu KELVIN CRISTIANO ALVES e sua destinação ao tráfico é indubitosa. Nesse sentido a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram os elementos informativos produzidos em sede policial.

Robson Rogerio de Moraes, policial militar ouvido em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento e avistaram dois indivíduos na praça, local dos fatos. Esses dois indivíduos estavam conversando. Maycon arremessou algo em direção à rua. Ambos tentaram se evadir, um para cada lado. Ambos foram abordados e com estes encontraram entorpecentes. Com Maycon ainda encontraram isqueiro e cachimbo. Ao verificar o que foi lançado na mesma rua, constataram se tratar de entorpecente. Conhecia ambos de oportunidades anteriores, Kelvin em razão de prisão anterior, e Maycon é conhecido como usuário. Maycon confessou informalmente o crime. Kelvin tinha consigo doze pedras de crack, o que é incompatível com o simples uso de entorpecentes.

Edilson Luis de Oliveira, policial militar ouvido em juízo, corroborou o depoimento de seu colega policial. Ressaltou que o local é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirma que um dos acusados – de branco em audiência – lançou objeto na rua. Encontraram entorpecentes com ambos. Um deles – acusado vestido de branco – afirmou que estava no local para vender entorpecentes. Esse foi questionado por qual razão estaria praticando tráfico de drogas, uma vez que é conhecido como usuário de entorpecentes. Teria então narrado para a equipe que

estava vendendo entorpecentes porque tinha dívida com o tráfico de drogas. O corréu Kelvin estaria cobrando a dívida e teria levado entorpecentes para que Maycon efetuasse a venda destes.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada. A alegação de que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é argumento suficiente a ponto de afastar a procedência da ação penal. Afinal, a lei processual não se vinculou ao regime da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados. Não há notícias de desvios funcionais anteriores dos policiais de modo que os seus depoimentos assumem importante valor probatório.

A respeito da chamada confissão informal, é certo que não se confunde com a própria confissão, uma vez que essa é ato personalíssimo, podendo inclusive ser retratada pelo imputado, tal como realizado em audiência de instrução. Assim, conquanto possa ser utilizada para corroborar demais meios de prova produzidos, tal não foi verificado durante a instrução processual, sendo insuficiente à comprovação da autoria delitiva do acusado Maycon.

Kelvin Cristiano Alves, em interrogatório judicial, afirmou que estava em saída temporária. Cumpria pena em regime semiaberto. Afirma que na data dos fatos iria à casa de seu irmão, próximo ao local em que foi preso com o acusado. Ao avistar Maycon, pediu-lhe informação. Neste momento foi abordado por viatura policial junto do acusado. Afirma que o entorpecente foi trazido pelo policial. Um dos policiais lhe perguntou se estava então traficando novamente já durante saída temporária. Afirma que Maycon disse que era usuário no momento. Afirmou que somente seria levado à delegacia como testemunha e então seria liberado, conforme dito por policiais no momento. O irmão do acusado Kelvin, conhecido pela alcunha de Gordo, presenciou momento em que policiais disseram que Kelvin somente seria encaminhado como testemunha. E tanto o é que foi conduzido em banco traseiro de viatura, sem algemas. Até o momento não sabe por que está preso. Pediu a Maycon que dissesse a verdade em audiência. Não tem recebido visitas no local em que está preso. Está preso no seguro, pois não tem qualquer envolvimento com facção criminosa. Nunca tinha visto Maycon antes. Nem mesmo sabia que o local em que foram presos é uma "biqueira". Seu irmão mora próximo ao local. Antes de ser preso, o local não era ponto de tráfico de drogas. Ressalta que somente perguntou horário a Maycon. Maycon realmente lançou entorpecente. No momento em que abordados, Maycon confessou a posse da droga e que estaria vendendo esta substância para consumir. Após foram afastados e com o corréu conversaram separadamente. A casa do irmão de Kelvin é bastante próxima à praça. Afirma que está no seguro atualmente porque sua vida é outra agora, está procurando trabalho. No raio normal tem muita população, falam sobre facção, e o acusado não quer pertencer a facções criminais. Diversamente do que consta em seu interrogatório policial, não foi ao local comprar entorpecentes, somente estava indo à casa de seu irmão. Não estava mais vendendo entorpecentes.

Maycon Viana Pontes, em interrogatório judicial, afirmou que somente estava no local para comprar entorpecentes. Compraria somente para uso. É usuário de entorpecentes. Estava comprando entorpecentes de Kelvin. Kelvin chegou a lhe entregar o entorpecente, mas não chegou a pagar. Antes de entregar o dinheiro para Kelvin, a polícia chegou. Então arremessou o entorpecentes que tinha adquirido na rua. Foi então ameaçado por Kelvin para que confessasse a traficância. Há mais de dez anos é usuário entorpecente. Aduziu que o corréu tentou com ele combinar para que confessasse os fatos em audiência.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

No caso, a negativa apresentada pelo réu permaneceu isolada Kelvin. Não há qualquer indício, mínimo que seja, que confira suporte à versão ofertada em autodefesa. Tentou, é certo, minimizar a sua responsabilidade pelos fatos.

A bem da verdade, o acusado Maycon apresenta versão coerente com o conjunto probatório produzido. Isto, pois os policiais ouvidos na ocasião apontam que Maycon é conhecido usuário de drogas da região, estranhando o fato de que este informou estar praticando tráfico de entorpecentes no momento. Destaca-se que com Maycon ainda encontraram isqueiro e cachimbo, o que é compatível com a versão por este apresentada em juízo, no sentido de que é somente usuário de entorpecentes e, na ocasião, fora ameaçado por Kelvin para que assumisse a propriedade da droga. Veja-se que com Kelvin nada compatível com a simples condição de usuário foi encontrado. E, ainda, ressaltam os policiais que com Kelvin também foi encontrada quantidade de droga incompatível com o uso.

Neste sentido, a narrativa acusatória encontra comprovação segura nos autos quanto à traficância praticada por Kelvin. Não foram produzidas provas aptas a refutar a tese de acusação. Isto é, não há qualquer elemento de prova que refute com dúvida concreta e razoável o juízo de certeza que sobre essa recai. Igualmente, sua versão alternativa apresentada é cabalmente refutada pela prova testemunhal produzida, pela versão do corréu Maycon, bem como pela apreensão de petrechos destinados ao uso de drogas com este.

Em síntese conclusiva, pelas provas produzidas durante o curso do processo, é possível constatar a existência do crime de tráfico. Nesse sentido, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, a variedade e a quantidade evidenciam, de modo patente, que o acusado KELVIN CRISTIANO ALVES estava no local para o exercício da traficância.

Quanto à Maycon, a solução é diversa. Não há prova suficiente para sua condenação pelo crime de tráfico imputado na denúncia. A prova acima já valorada impõe a readequação penal típica dos fatos para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Destaco que desnecessário o aditamento da denúncia na hipótese, pois o fato naturalístico imputado não é diverso.

Neste ponto, em que pese interpretação literal do disposto no art. 48, §1º da Lei n. 11.343/06 ("o agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais"), tenho que após a instrução do feito e a análise do mérito, não é o caso de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Trata-se, em verdade, de prorrogação da competência, fixada pela capitulação inicial e processamento do feito, tudo como autorizado pelo artigo 74, § 2º, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Sentença desclassificando a conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.3343/06, sem a devida aplicação da pena. Ordem de remessa ao Juizado Especial Criminal. Hipótese em que a E. Magistrada, entendendo que a hipótese não era de tráfico, mas de uso, deveria ter aplicado a reprimenda que entendesse cabível. Competência definida pela denúncia originalmente aceita. Sentença anulada de ofício. (TJSP; Apelação Criminal 0069613-98.2016.8.26.0050; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

Quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, tenho que enquanto a discussão no RE nº 635659/SP, com repercussão geral reconhecida, não for decidida em definitivo, deve prevalecer a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

II - Da individualização da pena

A) RÉU KELVIN CRISTIANO ALVES

Na primeira etapa de dosimetria de pena, o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, em relação à natureza, quanto mais forte for a droga ilícita, mais grave será a consequência em função da sua utilização. Em relação à quantidade, quanto maior for a quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. No caso, foi apreendida quantidade que não é significativa a ensejar um juízo de reprovabilidade mais rigoroso. Quanto às circunstâncias do art. 59, observo que desfavoráveis as circunstâncias do crime, uma vez que aproveitou-se de benefício de saída temporária, concedido em execução penal, para a prática do crime imputado. Ainda, desfavorável a culpabilidade do acusado, uma vez que ameaçou o corréu MAYCON, usuário de entorpecentes, a assumir a propriedade do entorpecente apreendido e a traficância a fim de afastar sua responsabilidade pelos atos praticados. Possui, ainda, maus antecedentes (processo n. 0002611-24.2015.8.26.0543 - fls. 60). Assim, a pena base deve ser majorada de 1/4, resultando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em segunda fase de cálculo presente a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado ostentava condenação penal transitada em julgado, por mais de uma vez, (certidões de fl. 58/60 - autos n. 0103643-62.2016.8.26.0050 e n. 0000028-95.2017.8.26.0543) quando do cometimento da presente conduta, não tendo ainda expirado o prazo de cinco anos, contados do cumprimento ou extinção da pena anterior. A multirreincidência justifica a exasperação da reprimenda acima do usual, de modo que a pena deverá ser acrescida de 1/5, totalizando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em terceira etapa de dosimetria de pena, afasto a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de acusado reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da causa diminuidora de reprimenda, conforme o texto legal. Ademais, a hipótese dos autos está bem distante da situação mais benéfica desenhada pelo legislador penal, qual seja, a microtraficância. Inviável a redução dos padrões de reprovabilidade penal. Veja-se que o STJ entende que "para a aplicação do privilégio contido no § 4º da Lei 11.343/2006, impõe-se ao agente a primariedade, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Evidenciado tratar-se de réu reincidente, ou que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, restam ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício." (STJ. AgRg no HC 335.385/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017). Por isso, a pena definitiva é fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, observada quantidade de pena, desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e reincidência, fixo regime inicial fechado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário,

comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E. Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019). Ressalto que não se trata de acusado primário e encontrava-se em cumprimento de pena quando de sua prisão, de modo que eventual progressão de regime depende de análise de eventual unificação de penas.

Pelo mesmo fundamento acima, quando da fixação do regime inicial para cumprimento da pena, no presente caso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Também, não há que se falar em suspensão condicional da pena, na medida em que a reprimenda supera os dois anos (art. 77, caput, do Código Penal).

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuir o réu boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

B) RÉU MAYCON VIANA PONTES

Verifico que o réu é reincidente – condenação nos autos n. 0010039-34.2015.8.26.0292 - fls. 68. Em razão disso não faz o réu jus aos benefícios da Lei n. 9.099/95, de forma que passo à dosimetria da pena

Considerando o histórico criminal do acusado apenas a condenação a pena de advertência não se mostra razoável. Sendo assim, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/06.

III – Dispositivo

Com supedâneo no exposto, julgo parcialmente procedente o pedido condenatório, formulado na imputação inicial oferecida pelo i. representante do Ministério Público, titular da ação penal, para: a) CONDENAR o réu KELVIN CRISTIANO ALVES às penas privativas de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; b) CONDENAR o acusado MAYCON VIANA PONTES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no crime tipificado pelo artigo 28, da Lei 11.343/06 e aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de três meses, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/06.

Não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva do imputado KELVIN CRISTIANO ALVES, de modo que não lhe faculta o recurso em liberdade. Por certo, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva." (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2017). Neste ponto, "a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio

Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Ainda, trata-se de condenado reincidente, o que indica a probabilidade de cometimento de futuros crimes. Já tendo recebido sanção penal anterior, e não ressoacializado, o imputado optou por dedicar-se à transgressão da ordem constituída, razão pela qual sua liberdade representa risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é a doutrina de Eugenio Pacelli de Oliveira: "Para além do fato de a maioria esmagadora dos países europeus (Alemanha, Espanha, Portugal, etc.) e também dos Estados Unidos incluírem a possibilidade de reiteração criminosa como hipótese de segregação cautelar, é de se observar que a experiência humana não pode ser inteiramente desconsiderada em determinadas situações da vida social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 529).

Defiro o recurso em liberdade ao acusado MAYCON VIANA PONTES.

Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 72 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova. Observe-se os arts. 524 a 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Com relação à quantia em dinheiro apreendida, evidente a sua vinculação com o tráfico. Determino o seu perdimento em favor da União. Oficie-se, observado o Comunicado CG Nº. 805/2019.

Condene ainda o acusado ao pagamento das custas processuais.

Com relação aos demais objetos apreendidos, aguarde-se por 90 dias manifestação da parte interessada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como demais ofícios necessários. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Ademais, revogado o artigo 393, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santa Isabel, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA